

1500772-55.2021.8.26.0129

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE ALFREDO DE ANDRADE FILHO

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... se profissão fosse. Logo, não se tratava de tráfico eventual, mas sim habitual, atividade usualmente desenvolvida pelo acusado".(Apelação nº 0000219-29.2017.8.26.0580 - 9ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des.Silmar Fernandes - julgado em 01/04/2020).

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

2ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500772-55.2021.8.26.0129 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500772-55.2021.8.26.0129

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2311855/2021 - DEL.POL.CASA BRANCA, 21417326 - DEL.POL.CASA BRANCA, 1236/21/203 -

DEL.POL.CASA BRANCA, 2311855 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 1236/21/203 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALEXSANDRO COSTA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ ALFREDO DE ANDRADE FILHO

Vistos.

ALEXSANDRO COSTA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, à qual me reporto, em 16 de novembro de 2021, por volta das 15h10min., na Rua dos Bonvicini n. 333, bairro Nazaré, nesta cidade e comarca de Casa Branca, trazia consigo, para fins de comercialização, 40 pedras de crack, pesando 3,4g de massa líquida², substância esta entorpecente e que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Realizada audiência de custódia, foi concedida ao autuado a liberdade provisória (fls. 27/29). A denúncia foi recebida aos 29 de novembro de 2021 (fls. 55/57). O acusado foi devidamente citado (fls. 117) e apresentou resposta à acusação (fls.

62/69). Durante a fase instrutória, foi inquirida uma testemunha e ao final o acusado foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, em debates orais, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia, ao passo que a Defesa a Defesa reiterou a defesa prévia.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente, em que pese a audiência de instrução não tenha sido presidida por este julgador, quando os autos vieram conclusos para sentença já havia cessado a designação da D. Magistrada que presidiu a instrução, razão pela qual passo a sentenciar o feito. Assim, o fato de a sentença ser proferida por julgador que não conduziu a instrução não enseja a nulidade do processo. Isso porque o art. 399, §2º, do Código de Processo Penal traz regra que deverá ser observada sempre que possível, mas que encontra exceções, dentre as quais o afastamento regulamentar do Magistrado que presidiu a instrução, caso dos autos. Nesse sentido:

"O princípio da identidade física do juiz pode ser excepcionado nos casos de convocação, licença, promoção, férias, ou outro motivo legal que impeça o (a) Magistrado (a) que presidiu a instrução sentenciar o feito. Precedentes. 2. No caso, a Magistrada que presidiu a audiência estava em gozo de férias regulamentares. Assim, a sentença condenatória proferida por outro Membro do Poder Judiciário é válida." (RHC 111.670/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019).

Demais disso, o processo penal, em tema de nulidades, é regido pela máxima *pas de nullité sans grief*, consagrado pelo legislador no art. 563 do CPP e pela jurisprudência na Súmula nº 523/STF, ou seja, não deve ser declarada nulidade quando não resultar prejuízo comprovado:

"A jurisprudência desta Corte Superior entende que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e pode ser mitigado. Em se tratando de nulidade relativa, necessária para o seu reconhecimento a demonstração de prejuízo pela parte" (STJ, AgRg no AREsp 1013335/DF, Sexta Turma, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 6/6/2018).

Feito tal esclarecimento, consigno que, embora tenha a Defesa técnica feito alegações finais remissivas, reportando-se aos termos da defesa escrita, não há que se falar em nulidade por ausência de defesa, pois, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal, "quanto à apresentação de alegações finais remissivas à resposta à acusação, por mais que seja sucinta, não acarreta prejuízo intrínseco, já que a defesa técnica não vislumbrou novas linhas defensivas além daquelas já apresentadas" (STF, HC 130.844, Rel. Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 21/03/2016, Publicação: 31/03/2016).

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/05), boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08), auto de constatação preliminar (fls. 09), laudo químico-toxicológico (fls. 40/42), relatório final (fls. 43/44), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria e a tipicidade da conduta imputada ao acusado também são certas e seguras, pois os depoimentos das testemunhas confirmam os delitos descritos na denúncia.

A testemunha Cristiano Donizete da Silva Antonialli, policial militar, em juízo, sob o crivo do contraditório, relatou, em resumo, que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento quando uma senhora informou-lhes informalmente que uma pessoa, branca, magra, trajando camiseta cinza e bermuda, estava vendendo drogas no bairro. Diante disso, efetuaram diligência, vindo a avistar uma pessoa com aquelas características. Quando essa pessoa notou a vitura, dispensou um objeto ao chão. Em seguida, referida pessoa foi abordada e foi identificada como sendo o acusado. Em poder do réu, nada de ilícito foi encontrado. Ato contínuo, apurou-se que o objeto dispensado pelo réu eram 40 pedras de crack e uma nota de R\$ 20,00. Questionado, o acusado confirmou que a droga era para venda. Afirmou que teve certeza de que foi o réu que dispensou o objeto. Disse, por fim, que a droga foi dispensada ao lado de

um ginásio.

Em solo policial, o acusado Alexsandro Costa dos Santos permaneceu em silêncio (fls. 04). Em Juízo, em seu interrogatório, sob o crivo do contraditório, declarou que é verdadeira a acusação. Admitiu que estava com a droga, bem como que estava traficando há dois dias.

Como se vê, a confissão do réu foi corroborada pela prova oral, notadamente pela o depoimento da testemunha, tanto aquele prestado em Juízo quanto os de solo policial (fl. 3), que se mostrou uníssono e coeso, descrevendo os fatos com clareza, relatando como o procedimento policial foi realizado, demonstrando categoricamente que as drogas encontradas destinavam-se ao tráfico.

Ressalte-se que a confissão é circunstância atenuante genérica e também meio de prova, sobretudo quando se mostra em consonância com a prova produzida sob o crivo do contraditório, o que ocorre no caso dos autos.

Pontuo que a maneira com que houve a abordagem, a natureza e a quantidade das drogas, a quantia em dinheiro apreendida, as circunstâncias fáticas autorizam o reconhecimento da prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, a condenação é medida que se impõe, uma vez que a prova produzida durante a fase instrutória foi bastante contundente ao revelar a dedicação do acusado à venda de entorpecentes e confirma toda a dinâmica dos fatos na forma narrada pela acusação na denúncia e explicitada pormenorizadamente pelas testemunhas de acusação.

Destaco que o delito foi praticado nas imediações de um ginásio, razão pela qual reconheço a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, invocada pelo Ministério Público. Assim sendo, considero o réu como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Isto posto, passo a dosar as penas.

Na primeira fase, em atenção ao disposto nos artigos 42 da Lei de drogas e 59 do Código Penal, observo que o acusado é primário (fls. 23/25). Ademais, Não há nos autos elementos desfavoráveis no tocante à conduta social e personalidade do acusado, nem aos motivos, circunstâncias e consequências do crime. Assim, considerando as circunstâncias mencionadas, fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. Todavia, a reprimenda não pode ser nesta fase da dosimetria fixada em patamar abaixo do mínimo legal (enunciado de Súmula nº 231 STJ).

Na terceira fase da dosimetria da pena, verifica-se a existência de causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei de Drogas. Não havendo causas de redução, torno definitiva a reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ressalto que o acusado não tem direito à causa de redução mencionada no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, porque esta regra não se coaduna com as circunstâncias deste caso concreto. Friso que, embora Alexsandro seja primário, trazia consigo quarenta pedras de crack, indicativo de intensidade da mercancia deletéria e de vasta clientela. Óbvio, portanto, que não se trata de traficante jejuno. Aliás, o próprio réu admitiu que estava traficando há dois dias. E é evidente que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional, episódica, hipótese com a qual, repita-se, não se identifica o caso vertente.

Confira-se:

"A exposição quanto a primariedade e pouco tempo de conduta criminoso não prospera pela colidência com a condição fático-lógica de traficar nessas condições. Não é traficante iniciante, jejuno no crime, que tem tal disponibilidade de oferta. Ainda que não poderoso no tráfico, trata-se de microempreendedor dedicado, interessado em evoluir. Tudo isso impede a concessão do redutor".(Apelação nº 0069814-95.2018.8.26.0050 - 3ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - julgado em 01/04/2020).

"Como se pode observar, para que haja a redução da pena com fundamento no dispositivo acima descrito não basta que o acusado seja primário e ostente bons antecedentes. É necessário que, concomitantemente a tais requisitos, haja a constatação de que ele não se dedica a atividades criminosas e não integra

organização criminosa. No caso dos autos, verifica-se que o réu foi surpreendido com grande quantidade de maconha, totalizando quase um quilograma. Todas as questões apontadas demonstram, extirpe de dúvidas, que o réu fazia da narcotraficância seu meio de vida; a venda de drogas era, pois, o modo como auferia renda para sobreviver, como se profissão fosse. Logo, não se tratava de tráfico eventual, mas sim habitual, atividade usualmente desenvolvida pelo acusado".(Apelação nº 0000219-29.2017.8.26.0580 – 9ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des.Silmar Fernandes – julgado em 01/04/2020).

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 44 DO CP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] - Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

- Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n.11.343/2006. Precedentes.

- Hipótese em que o Tribunal de origem conferiu legalidade à manutenção do não reconhecimento do privilégio, ao fundamentar que a quantidade, a variedade e a nocividade dos entorpecentes apreendidos (15,13 gramas de cocaína e 26,23 gramas de crack), aliadas às circunstâncias em que o delito ocorreu, permitem concluir que o acusado dedica-se a atividades criminosas. Modificar tal conclusão requer o revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.

- Mantida a condenação em patamar superior a 4 anos, resulta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP.

- Habeas corpus não conhecido." (HC 362.266/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/09/2016).

Por tudo isso e considerando sobremaneira que há provas suficientes de que o réu se dedica de maneira não casual ao tráfico de drogas, é de se afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição em tela.

A despeito da primariedade do acusado restou comprovado o envolvimento não ocasional dele no comércio espúrio de tóxicos. No mais, o delito é apenas com reclusão (CPP, art. 313, I), além do seu caráter hediondo, a justificar modalidade mais severa e maior rigor penitenciário para início de desconto da segregativa.

Além disso, o réu foi abordado nas proximidades de uma ginásio, enquanto trazia consigo drogas para fins de tráfico. Portanto, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, por ser o único condizente com o princípio da suficiência dada a gravidade do delito, que perturba a ordem social, alicia e corrompe crianças e adolescentes, aniquila a força produtiva de usuários e viciados e fomenta a criminalidade, produzindo efeitos deletérios a toda coletividade, a exigir tratamento mais rigoroso sob pena de a reprimenda não alcançar, a contento, sua finalidade preventiva e retributiva.

Não se mostra socialmente recomendável, diante da quantidade de drogas e da prática nas proximidades de ginásio, a substituição da pena privativa de liberdade por por restritivas de direitos, a qual não se mostra suficiente para reprovação do crime (artigo 44, inciso III, do Código Penal). Pelas mesmas razões, entendo incabível a aplicação do sursis (artigo 77, inciso II do Código Penal). Realmente, tais medidas

não se coadunam com a necessidade de segregação do acusado, que comercializava crack, substância perniciososa e causadora de dependência física e psíquica. Deixo de aplicar o §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, porquanto o regime não fora fixado com base na quantidade de pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida nestes autos para o fim de condenar o réu ALEXSANDRO COSTA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º). Custas na forma da lei.

Embora preso em flagrante, obteve a liberdade provisória em audiência de custódia e assim permaneceu no curso da instrução, de tal modo que, em respeito ao princípio da contemporaneidade (art. 315, §1º do CPP), não há razão, à míngua de superveniente motivo a ensejar o encarceramento provisório, para o decreto de segregação cautelar nestes autos, em que pese a gravidade em concreto do delito. Já houve autorização para destruição da droga apreendida (fls. 28).

Quanto à quantia apreendida nos autos, considerando que o acusado não comprovou a origem lícita dos valores e tendo em vista que tal importância guarda correlação com crime de tráfico de drogas, evidenciando que se trata de produto da mercancia de drogas, decreto o perdimento dos valores em favor da União (art. 63, caput e § 1º da Lei nº 11.343/06).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários, no valor máximo, em prol da i. Advogada que atuou no feito em função do convênio da assistência judiciária.

Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); (2) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); (3) intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa (art. 50, caput do CP); (4) após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Casa Branca, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA